

1506009-50.2021.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como a droga estava embalada, características típicas da destinação ao narcotráfico, além do fato de se tratar de ponto conhecido de venda de drogas, como afirmaram os guardas civis.

Embora o acusado negue envolvimento com as porções apreendidas, o depoimento prestado pelos guardas civis foi seguro no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1506009-50.2021.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506009-50.2021.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CESAR AUGUSTO CUNHA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Cesar Augusto Cunha, menor de 21 anos, foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 01º de dezembro de 2021, por volta das 08h30min, na Rua Honório Franco da Rocha, altura do numeral 163, Jardim Santa Terezinha, neste Município e Comarca de Mogi Guaçu, nas imediações de duas praças públicas, do estabelecimento de ensino "CEI Padre Longino Vastbinder" e da entidade beneficente ADEFIVI, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico e entrega a terceiros, 49 (quarenta e nove) microtubos contendo cocaína, pesando 34 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, e o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O acusado apresentou defesa prévia (fls. 66/70) e a denúncia foi recebida aos 09 de fevereiro de 2022 (fls. 71/73).

A representante do Ministério Público pugna pela procedência da ação penal e condenação do acusado nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer a improcedência da ação penal, com consequente absolvição do réu, sustentando que a prova produzida é insuficiente para a condenação. No caso de condenação, requer benesses quanto à pena aplicável.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 08/09), pelo laudo pericial do local (fls. 48/53); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 45/47) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O guarda municipal Luís Carlos Pereira disse que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, ponto conhecido de venda de drogas, e avistou o acusado, abaixado e mexendo em um entulho. Realizou a abordagem e, em revista pessoal, nada ilícito foi encontrado, porém, no entulho foram encontrados 12 pinos de cocaína soltos e 37 pinos de cocaína dentro de um invólucro preto. Questionado, confirmou que havia assumido a prática do tráfico de drogas no período da manhã daquela data. Disse que havia dois rapazes nas imediações, que também foram abordados, mas com eles nada ilícito foi apreendido, assim como eles não foram vistos no entulho onde as porções foram apreendidas.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo guarda municipal Maicon André Souza de Abreu Fernandes, que acrescentou que o acusado dispensou objeto no chão ao perceber a viatura. Efetuiu a revista e nada ilícito apreendeu. No local onde o acusado mexia inicialmente, monte de entulho, encontrou 37 pinos de cocaína, bem como outros 12 dispensados por ele.

Em solo policial, o acusado César Augusto Cunha permaneceu calado (fls. 06).

Em juízo, o acusado disse que a acusação não é verdadeira. Informa que passava pelo local do fato e viu a abordagem a dois rapazes. Nisso, o interrogando também foi abordado, mas nega que tenha mexido no entulho, onde viu os guardas encontrarem as drogas. O guarda civil Maicon já havia prometido prender o interrogando por tê-lo visto com frequência no local.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como a droga estava embalada, características típicas da destinação ao narcotráfico, além do fato de se tratar de ponto conhecido de venda de drogas, como afirmaram os guardas civis.

Embora o acusado negue envolvimento com as porções apreendidas, o depoimento prestado pelos guardas civis foi seguro no sentido de que visualizaram o momento em que o acusado mexeu em objeto exatamente no local onde, posteriormente, apreenderam as diversas porções de cocaína.

Há que se destacar que os guardas informaram que viram o acusado agachado exatamente no local onde as porções foram apreendidas, sendo que o próprio acusado relatou que não conhecia o guarda civil Luís Carlos Pereira, de modo que não se pode imaginar tenha interesse de deliberadamente prejudicar o acusado.

Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado trazia consigo quantidade expressiva de droga acondicionada de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

“O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples

possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663). "Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos guardas municipais na medida em que o próprio acusado disse que não tinha nada contra os agentes, de modo que não se vislumbra nenhum indício para imputarem falsamente o crime ao acusado. Ressalta-se ainda, que os depoimentos dos guardas municipais foram harmônicos e coesos, não restando dúvidas quanto à dinâmica dos fatos.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, entendo que a quantidade de droga apreendida não é expressiva a ponto de justificar o recrudesimento da pena nesta fase, de modo que fixo a pena privativa de liberdade em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, anotando-se que o laudo pericial indicou que a massa líquida da substância apreendida é de 6 gramas.

Em segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa, sem reflexo sobre a pena estipulada, pois já fixada no mínimo legal (súmula 231 do STJ).

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial (fls. 48/53) revela que nas imediações do local onde os fatos ocorreram existem estabelecimento de ensino e praças públicas, o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas devido ao maior fluxo de pessoas.

Aliás, a lei não exige que aquele seja o local especialmente visado pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas "Zumira" e "Rubens Leme Asprino" (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal) Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que "(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias." (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Por estes fundamentos, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa.

Ainda em terceira fase, não incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, porque o acusado ostenta anterior execução de medida

socioeducativa (fls. 24), em razão da prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas, conforme demonstram os documentos de fls. 106/113.

Assim, é o caso de se obstar por completo a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º da lei n. 11.343/06, pois o artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, exige que o agente não se dedique a atividades criminosas, não havendo menção à existência de sentença condenatória ou que o envolvimento se refira apenas ao período da maioridade penal, sendo mesmo possível considerar o tempo de inimizabilidade para avaliar se o réu faz jus às benesses daquele dispositivo. A esse respeito:

Ainda nessa etapa, no meu ponto de vista, realmente não é caso de se aplicar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas ao apelante, já que compartilho do entendimento do Juiz sentenciante no sentido de que ficou demonstrado que ele se dedicava a atividades criminosas, em razão de ter admitido que vendia drogas há uma semana, além de já possuir um registro por ato infracional perpetrado quando adolescente, equiparado ao tráfico (TJSP, Autos n. 007605-85.2017, Relator Des. Nelson Fonseca Júnior, 10ª Câmara de Direito Criminal, julgado aos 23/8/2018).

"[a] existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais" (STJ, AgRg no REsp nº 1.560.667- SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. em 17.10.2017, DJe 23.10.2017).

Como já dito, ostentando envolvimento em atividades criminosas, por força da prática do narcotráfico desde a época em que menor de dezoito anos de idade, o agente não faz jus ao benefício destinado a iniciantes na seara delitiva, razão pela qual fica afastada a aplicação da minorante mencionada, não havendo que se acolher a impugnação formulada pela defesa ao teor da documentação de fls. 106/113. Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

De acordo com o total de pena imposta e porque favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto. Nesse sentir: AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.

IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME FECHADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO. DESCABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRADO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agrado regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente

firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas (tráfico), em razão não somente pela quantidade de drogas apreendidas, mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição, como reclama a impetrante, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. III - Considerada a quantidade de pena aplicada (5 anos de reclusão), bem como fixada a pena-base no mínimo legal, em virtude da análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constata-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da imposição do regime fechado, de sorte que o paciente faz jus ao regime inicial semiaberto, o qual se revela como o mais adequado à prevenção e à repressão do delito em tela, conforme o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. IV - Mantida a pena cominada ao paciente em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, resta prejudicado o pedido de substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal. Agrado regimental desprovido.

(....)

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, insta consignar que o Pleno do eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 111.840/ES, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/2007, por ofender a garantia constitucional de individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal). Afastou, dessa forma, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e dos demais delitos a eles equiparados. Em tal contexto, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o Julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). Na hipótese, verifica-se nos excertos acima colacionados que o v. acórdão impugnado manteve o regime prisional fechado, amparando-se tão somente na hediondez do delito (tráfico de drogas), sem indicar elementos concretos dos autos que demonstrassem a real necessidade de imposição de regime prisional mais gravoso, o que vai de encontro ao teor dos Enunciados ns. 718 e 719 da Súmula do STF, bem como do Enunciado n. 440 da Súmula do STJ, que assim dispõem:

(....)

Sob essa perspectiva, considerada a quantidade de pena aplicada (5 anos de reclusão), bem como fixada a pena-base no mínimo legal, em virtude da análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constata-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da imposição do regime fechado, de sorte que o paciente faz jus ao regime inicial semiaberto, o qual se revela como o mais adequado à prevenção e à repressão do delito em tela, conforme o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 604.250 – SP, julgado aos 6/10/2020, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma)

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Por estas razões, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Cesar Augusto Cunha à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhes nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que o crime de tráfico de droga atenta contra a ordem pública, fustigada pelo avassalador crescimento dessa prática espúria, bem como porque o acusado ostenta vasto histórico de envolvimento em atos infracionais, o que indica que sua liberdade configura risco concreto à ordem pública.

A esse respeito, já decidiu o C. STJ que: “Embora o registro de ato infracional não possa ser utilizado para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, podem ser sopesados na análise da personalidade do recorrente, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária. Precedentes.” (5ª Turma – HC 466.866/PE, j. 02/10/2018). Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime. Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 17 de março de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA